

0092508-53.2016.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/02/2022

... pelo próprio réu, o que configura tráfico e não uso de drogas.

Assim, uma vez que o réu foi surpreendido trazendo consigo e vendendo, considerável quantidade de substância entorpecente, não se pode falar em guarda para consumo próprio, com a consequente desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06, mas sim em tráfico ilícito.

É sabido que se tem ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0092508-53.2016.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0092508-53.2016.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 9684/2016 - 69º Distrito Policial - Teotônio Vilela

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL RIBEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

Rafael Ribeiro, qualificado nos autos na fl. 15, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, porque no dia 02/novembro/2016, por volta das 21h40, na Rua Adelza Gomes Vitoriano, altura do nº 10, Aricanduva, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para fins de comércio e consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 18,9g de cocaína, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a

determinação regulamentar e legal.

De acordo com a denúncia, na data e local dos fatos, conhecido ponto de tráfico de entorpecentes, o indiciado trazia consigo, para fins de comércio, 27 invólucros plásticos com cocaína, e estava vendendo uma porção de cocaína para Denerson Viana Pacheco; policiais civis em patrulhamento pelo local, surpreenderam o indiciado comercializando a droga e abordaram o vendedor e o consumidor; realizada revista pessoal, os policiais civis localizaram e apreenderam, em poder do indiciado, as drogas acima especificadas.

A denúncia (fls. 61/62) veio acompanhada do Inquérito Policial (fls. 01/29) e a peça acusatória foi recebida em 22/março/2017 (fls. 71/72); o réu constituiu defensor (fl. 102) e apresentou de sua Defesa Preliminar (fl. 131).

Realizada a instrução foram ouvidas duas testemunhas, sendo o acusado interrogado ao final (áudio audiência virtual - sistema Teams).

Nas suas considerações finais, o Ministério Público pediu o acolhimento da pretensão punitiva nos exatos termos da denúncia, pretendendo sua condenação à pena mínima prevista em lei, inclusive com aplicação do regime aberto; a Defesa pugnou pela extinção da punibilidade do réu com base na prescrição.

O laudo de constatação prévia encontra-se nas fls. 13/14 e o de exame químico toxicológico nas fls. 160/162; o auto de exibição e apreensão encontra-se nas fls. 11/12.

É o relatório.

Decido.

Ao término da instrução, verificou-se que os fatos narrados na exordial restaram comprovados, razão pela qual a ação deve ser julgada a favor da Justiça Pública. Na fase investigativa o réu confessou a autoria delitiva (fls. 07).

Interrogado em juízo, o acusado Rafael Ribeiro, 26 anos, confessou ter sido detido com cocaína naquele dia; estava vendendo as drogas (áudio sistema SAJ).

Vejamos o que disseram as testemunhas ouvidas em juízo.

O depoente Arnaldo Luis Baruzzi, policial civil, disse que, em patrulhamento de rotina viu dois rapazes como se estivessem tratando da venda de drogas; o réu tinha as drogas no bolso e o comprador confirmou que estava lá adquirindo entorpecentes (áudio sistema SAJ).

A testemunha Thyago Cursino Zaparolli, policial civil, disse que, em patrulhamento, visualizou um rapaz adquirindo drogas do réu; abordados, encontrou com o denunciado, em seu bolso, cerca de 27 papelotes de cocaína (áudio sistema SAJ).

Portanto, as testemunhas responsáveis pelo flagrante ouvidas durante a instrução confirmaram que toda a droga apreendida estava na posse do réu, sendo que ele estava realizando tratativa de venda com usuário quando foi abordado.

Com sua conduta, o réu se enquadra em, pelo menos, dois verbos do tipo previsto no artigo 33 da lei especial: trazer consigo e vender.

Destarte, verifica-se que a ação penal procede.

De fato, os depoimentos dos policiais foram claros, serenos e seguros, dando conta da apreensão em poder do acusado, em sua posse, de expressiva quantidade de substâncias entorpecentes, o suficiente a denotar o intuito da traficância.

A materialidade está estampada no Boletim de Ocorrência (fls. 08/11), no Auto de Constatação Prévia (fls. 13/14) e no Exame Químico Toxicológico (fls. 160/162).

Este último demonstra que a substância apreendida realmente era cocaína.

Como visto, os depoimentos dos policiais ouvidos em Juízo são coerentes e harmônicos e traduzem a certeza de que o réu, efetivamente, trazia consigo e vendia, cocaína.

Portanto, restou claro que os policiais prenderam o denunciado em flagrante em plena conduta típica, apreendendo em seu poder certa quantidade de cocaína.

Bem sabemos, como já dito acima, que incide nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, aquele que é detido com expressiva quantidade de substância tóxica.

No caso concreto, a droga estava sendo trazida e vendida pelo próprio réu, o que configura tráfico e não uso de drogas.

Assim, uma vez que o réu foi surpreendido trazendo consigo e vendendo, considerável quantidade de substância entorpecente, não se pode falar em guarda para consumo próprio, com a consequente desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da

Lei 11.343/06, mas sim em tráfico ilícito.

É sabido que se tem reiteradamente decidido que para a caracterização do delito previsto no artigo 33, não se faz necessário seja o infrator colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida. Tratando-se de crime de mera conduta, ter em depósito, guardar, transportar, trazer consigo, não importa a modalidade, forçoso reconhecer-se à configuração do crime em tela.

Ademais, mister se faz atentar para a natureza e a quantidade da substância apreendida (18,9g gr. de cocaína), o local (bolso da vestimenta) e as condições em que se desenvolveu a atividade delituosa (policiais em patrulhamento em local conhecido pela traficância visualizaram o acusado vendendo entorpecente a usuário, ocasião em que foi abordado e as drogas localizadas).

Ante o exposto, conclui-se que o contexto probatório é harmônico e coerente; robusto o bastante a embasar a expedição de um édito condenatório.

O réu realizou conduta antijurídica que se subsume em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se a condenação e a pena que passo a dosar, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

DOSIMETRIA

Prevê o art. 68 do Código Penal que a pena base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste código (circunstâncias judiciais); em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes (art. 65) e agravantes (arts. 61 e 62); por último, as causas de diminuição e de aumento, entendidas estas últimas como sendo os fatores de acréscimo ou redução da pena, assinalados em quantidades fixas (dobro, metade etc) ou em limites (um a dois terços etc), previstos na parte geral ou especial do Cód. Penal (cf. Código Penal Comentado, Celso Delmanto, 2ª ed. Renovar, p.120).

Já o art. 59 dispõe que o Juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime: as penas aplicáveis dentre as cominadas; a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Prevê o artigo 42 da Lei nº. 11.343/06: O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

O réu é primário (fls. 75/76).

Sua culpabilidade, entendida como índice de reprovabilidade de sua conduta, no caso, é de média intensidade.

Sua personalidade e conduta social não de ser tidos por média intensidade.

Atento, ainda, ao motivo do delito - qual seja, o ânimo de auferir lucro, já que se dispôs a trazer a droga no meio da rua - bem como, atento às circunstâncias e funestas consequências da infração, que degrada a pessoa e compromete o tecido social e, em especial, considerando a quantidade de substâncias entorpecentes que o acusado trazia consigo, com os malefícios de todos conhecidos, fixo a pena base no mínimo legal de 05 (cinco) anos e de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.

Deixo de reconhecer a atenuante da confissão, uma vez que a pena foi fixada em seu mínimo legal.

Por fim, o acusado faz jus à causa de diminuição prevista no parágrafo 4º, do artigo 33 da nova lei de entorpecentes, eis que é primário e possui bons antecedentes, devendo sua pena ser reduzida no patamar de 2/3 (dois terços), chegando-se a pena final de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, a qual torno definitiva na ausência de outras modificadoras.

Cada dia multa fica fixado no valor mínimo previsto na lei especial, dada a pouca fortuna do réu, dado que emerge dos autos.

Fixo regime inicial aberto para início de cumprimento da pena.

Anoto que, este posicionamento, neste caso, partiu da necessidade de proporcionar ao réu uma nova oportunidade, pois não adianta somente castigar o indivíduo; retirá-lo do convívio da sociedade e de seus familiares, da possibilidade de conseguir sustentar-se e encarcerá-lo novamente gerará uma revolta; a descrença na justiça será enorme; sua não reinserção na sociedade fará com que acabe praticando novas infrações e, atolando ainda mais o sistema carcerário.

DECISÃO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA DEDUZIDA EM JUÍZO e o faço para declarar Rafael Ribeiro, qualificado nos autos na fl. 15, incurso no artigo 33, caput, c.c. parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento da pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, cada qual no valor mínimo legal, ante a pouca fortuna do condenado, dado emergente dos autos.

Preenchendo o acusado os requisitos do artigo 43 e seguintes do Código Penal, converto sua pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, quais sejam, uma prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas a critério do Juízo das Execuções Criminais, mais pagamento de 10 (dez) dias multa.

Neste sentido:

APELAÇÃO - Tráfico de drogas - Apelo do Ministério Público desprovido - Quantidade de entorpecente apreendida que não pode ser considerada expressiva, razão pela qual a pena-base deve ser mantida no mínimo legal - Ausente prova de que o réu se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa - Cabível o reconhecimento do chamado tráfico privilegiado, com a redução da pena, em sua fração máxima (2/3), nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 - Viável a substituição da reclusiva por duas penas alternativas, consistentes em prestação de serviços comunitários e outra multa - Também deve ser modificado o regime inicial para o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do CP - Precedentes do C. STJ e do E. STF - APELO DO MP DESPROVIDO - RECURSO DEFENSIVO PROVIDO para reduzir as penas a 01 ano e 08 meses de reclusão, além de 166 dias-multa, bem como para modificar o regime para o aberto, substituindo-se a reclusiva por penas restritivas de direitos - Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado. (TJSP; Apelação Criminal 1500317-90.2018.8.26.0551; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/07/2020; Data de Registro: 10/07/2020)

Tráfico de drogas. Conduta de trazer consigo, expor à venda e guardar 46 porções de cocaína. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Pretendida absolvição. Inadmissibilidade. Depoimentos de policiais militares que efetuaram a prisão. Usuário surpreendido no momento da abordagem que afirmou ter adquirido entorpecente do réu. Validade e suficiência para a procedência da ação penal. Circunstâncias da prisão e modo de acondicionamento indicativos do intuito mercantil. Condenação mantida. PENA. Majorante referente à proximidade de igrejas e estabelecimentos de ensino que não pode ser mantida. Absoluta ausência de indicativos no sentido de que a traficância colocava em risco os seus frequentadores. Redução para 1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias-multa. Substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos. Admissibilidade. Inconstitucionalidade das vedações da Lei 11.343/06. Violação ao princípio da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CF). Precedentes do STF e do STJ. Conversão da pena reclusiva em restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Inteligência do artigo 44, § 2º, parte final, do CP. Imposição do regime aberto. Apelo defensivo parcialmente provido para esse fim. (TJSP; Apelação Criminal 0000271-94.2017.8.26.0557; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Barretos - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/07/2020; Data de Registro: 08/07/2020)

O réu era menor de 21 anos na época dos fatos.

Neste contexto, considerando a pena em concreto aplicada, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão

punitiva em abstrato na forma retroativa, já que entre a data do recebimento da denúncia (22/03/2017) até a presente data, transcorreram mais de 04 anos e 10 meses.

Assim, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c.c. artigo 109, inciso V, c.c. artigo 115, todos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de RAFAEL RIBEIRO. Nos termos do artigo 63, caput e §1º, da Lei 11.343/2.006, determino, se for o caso, o perdimento do valor apreendido em favor da União.

Nos termos do artigo 72 da Lei 11.343/06, determino a destruição das drogas armazenadas para contraprova, no prazo máximo de 30 dias, devendo a autoridade policial enviar termo da incineração.

Por fim, como está sendo assistido pela Defensoria Pública, isento o réu do pagamento das custas por ser beneficiário da gratuidade processual.

P . I . C .

São Paulo, 4 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA